

1503541-93.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... também já foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de entorpecentes, autos nº 0087832-48.2005.8.26.0050, que será utilizado como maus antecedentes.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 59 do Código Penal, a pena deve ser majorada em 1/6, perfazendo 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração da condenação acima apontada apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503541-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503541-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ PROCOPIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

ANDRÉ PROCÓPIO e WILLIAM COSTA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157 § 2º, inciso II, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal porque no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 20h45min., na Rua Barão do Rio Branco, Santo Amaro, nesta Capital, agindo em concurso e com identidade de propósitos, bem como mediante grave ameaça, tentaram subtrair, para proveito comum, o veículo pertencente à vítima M. R.F.M.

A denúncia foi recebida. Os acusados foram citados e notificados e apresentaram resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, dois policiais e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, buscando a condenação apenas do acusado André, e a absolvição de William, com base no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa dos acusados, por sua vez, pugnou pela absolvição de ambos por insuficiência probatória para a condenação. E não sendo esse o entendimento que a pena seja fixada no mínimo legal, com redução pela tentativa em seu grau máximo e ainda a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No que tange ao corréu William, de fato, como muito bem ponderado pelas partes, não há nos autos provas de sua participação no crime em testilha.

Isso porque a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvido narrou que trabalhava como motorista de aplicativo - UBER - e na data dos fatos, conduzia seu veículo pela Rua Barão do Rio Branco, quando parou num sinal vermelho, momento que o réu André, que estava sozinho, colocou as mãos na cintura como se estivesse armado e anunciou assalto, mandando sair do carro. No entanto, acelerou seu veículo e fugiu do local.

Logo em seguida, retornou ao local, em que fora abordado e viu o mesmo indivíduo que deste vez estava na companhia de outra pessoa e novamente eles cercaram o veículo, mas também conseguiu se desvencilhar de ambos e novamente fugir. Em seguida, visualizou um viatura da polícia e relatou o ocorrido, passando as características de ambos que foram presos pela da Polícia Militar. Asseverou que André foi o indivíduo que o abordou na primeira vez e que da segunda vez ele estava na companhia de William.

Os dois policiais militares, por sua vez, após prestarem o compromisso de dizer a verdade, alegaram que estavam em patrulhamento de rotina pela via pública, e foram comunicados da tentativa de roubo pela própria vítima, que segunda ela fora abordada por dois indivíduos mas conseguiu fugir.

De posse do local dos fatos e também das características físicas dos roubadores se dirigiram ao local e encontraram os réus que foram levados à Delegacia de Polícia, para eventual reconhecimento por parte do ofendido.

Os réus ao serem ouvidos em juízo negaram a prática do crime, afirmando ainda, que não estavam juntos e sequer se conheciam.

Estas são as provas colhidas e diante delas, não há como se presumir que o réu William praticou qualquer ato típico de roubo na medida em que segundo a própria vítima, ele apenas estava na companhia de André e cercou seu veículo, ocasião em que disse que "só queria uma ajuda".

Ora, diante das próprias palavras da vítima, nesse segundo momento em que foi abordado pelos dois indivíduos, não houve qualquer ameaça ou mesmo violência, aliás, a vítima sequer narrou qualquer ato típico de uma tentativa de roubo.

Assim, diante dessas provas colhidas não há elementos suficientes para embasar uma condenação. Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Sendo assim a absolvição do acusado William é a única medida cabível.

Já no que toca ao corréu André outra sorte lhe convém.

Isso porque, a vítima foi enfática em afirmar estava com seu veículo parado aguardando o sinal e foi abordado pelo réu, que fingindo estar armado anunciou o assalto, determinando sua saída do veículo. É fato que afirmou que o réu parecia estar embriagado e que conseguiu acelerar o automóvel e sair do local.

Tal alegação contudo não tem o condão de afastar o delito de roubo tentado, como pretende a Defesa do acusado, já que conforme dispõe o art. 28 do Código Penal, a embriaguez, voluntária e culposa, que diga-se de passagem sequer foi comprovada nos autos, não exclui a imputabilidade penal.

Assim sendo, com relação ao roubo tentado praticado apenas pelo corréu André, a condenação do acusado, é medida de rigor, não sendo demais lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes praticados na clandestinidade. Neste sentido:

"Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na

jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Sem dúvida, assim, que a insuficiência probatória reclamada pela defesa não veio a ocorrer, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, contudo não veio comprovada nos autos, já que a vítima afirmou que na primeira abordagem, foi abordado apenas por André, que estava sozinho e que acelerou o veículo e conseguiu fugir.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. O réu é reincidente já que possui condenação transitada em julgado pelo crime de receptação, oriunda do processo número 0074803-47.2013.8.26.0050, que tramitou perante a 13ª Vara Criminal, cuja pena foi extinta em 28/07/2017, consoante certidão de fls. 70, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, também já foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de entorpecentes, autos nº 0087832-48.2005.8.26.0050, que será utilizado como Maus Antecedentes. Assim, nos termos do que dispõe o art. 59 do Código Penal, a pena deve ser majorada em 1/6, perfazendo 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não há que se falar em descon sideração da condenação acima apontada apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado ela não pode mais ser considerada como agravante em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de que seja tida como Maus Antecedentes, já que demonstra a personalidade criminoso do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Veja-se que a expressão "muito antigas", utilizada frequentemente para requerer o

afastamento das condenações é imprecisa e pode por vezes levar a situações de injustiça e até de quebra do princípio da individualização da pena, devendo o critério do julgador ser objetivo e fundado em fatos concretos, como os aqui apontados.

Na segunda fase, há que se reconhecer a reincidência e a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, em face da tentativa a pena deve ser diminuída em 1/2, considerando, sobretudo o iter criminis percorrido pelo que acusado, já que após ser ameaçada pelo réu que colocou as mãos na cintura, como se estivesse portando uma arma de fogo, o vítima conseguiu acelerar o veículo e assim impedir que a subtração ocorresse.

Assim sendo, aplica-se ao acusado a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 06 dias-multa.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para o fim de condenar o réu André Procópio, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 06 dias-multa, por estar incurso no artigo 157, "caput", combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal já que não há nos autos provas de sua condição financeira, e ainda para absolver WILLIAM COSTA DOS SANTOS, da acusação de roubo, posta na denúncia, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, pois é o único que convém ao acusado que é reincidente e ainda possui antecedentes criminais atestados nos autos.

Seja ainda, pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, pois solto novamente voltou a delinquir.

O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo (JUTACrim 88/87).

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontestável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

No mais, é certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP.

Nessa conformidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da pena" (RT 725/533).

"O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2º, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido" (STJ, Resp. 84669/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 14.4.97).

"Embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe12/02/2021).

Deixo de computar o período de prisão provisória do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da

Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.

O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal.

No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.

A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.

DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP.” (AgRg no

HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

"HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)". (HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Por fim, não poderá apelar desta em liberdade, pois o acusado já se encontra custodiados em razão do flagrante e um dos efeitos da sentença condenatória é justamente conservar preso aquele que já se encontra custodiado, não sendo recomendável que seja o réu agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva.

Assim sendo, recomende-se-o na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD. Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada do cálculo aos autos abra-se vista às partes para devida ciência e eventual manifestação.

Condeno ainda o acusado André, ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não podem arcar com essa despesa, sem prejudicar os seus sustentos.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá, o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). Em face da absolvição de WILLIAM COSTA DOS SANTOS, expeça-se alvará de soltura, clausulado, com urgência e após o trânsito em julgado para as partes, com relação a ele arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA